

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2414/2551

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

ฟิลิป มอรรริส โปรดักต์ส เอส. อา. กับ

พวก

โจทก์ร่วม

นายสมจิตร ดวงจำดอก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 226

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26

จำเลยไปที่บ้านของ ว. พร้อมกับทนายความและเจ้าพนักงานตำรวจอีกคนหนึ่ง เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเบิกเงินของ บ. และการใช้กระแสไฟฟ้าจากโรงงานจำเลย โดยเจ้าพนักงานตำรวจผู้นั้นได้แอบบันทึกเหตุการณ์ทั้งภาพและเสียงไว้ด้วย พฤติการณ์ในการบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการลักลอบกระทำก่อนวันที่จำเลยอ้าง ตนเองเข้าเบิกความเป็นพยานเพียง 1 วัน เพราะต้องการจะได้ข้อมูลที่แอบบันทึกไว้ เนื่องจากจำเลยฉีกเอกสารหลักฐานที่ว่าจ้าง บ. ก่อสร้างโรงงานทิ้งไปแล้ว จึง พยายามหาหลักฐานใหม่ ดังนั้น ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นพยานหลักฐานที่จำเลยทำขึ้น ใหม่ด้วยการทำเป็นดีกับ ว. แล้วลักลอบบันทึกเหตุการณ์นั้นไว้ ถือได้ว่า เป็นพยาน หลักฐานที่เกิดขึ้นจากการหลอกลวงและด้วยวิธีการที่มิชอบ ต้องห้ามมิให้อ้างเป็น พยานหลักฐานตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ มาตรา 26
ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา 226

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 มาตรา 5, 6, 7, 8, 11, 45, 48 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 4, 5, 17, 19, 20, 24, 43, 44, 48, 49, 50, 53 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4, 108, 110, 115, 117 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83, 90, 91, 254, 257, 264, 265, 266, 268 และสั่งริบของกลางให้เป็นของกรมสรรพสามิต

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายทั้งสามยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางอนุญาตโดยให้เรียกผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 ซึ่งได้ความว่าเป็นนิติบุคคลเดียวกันว่าโจทก์ร่วมที่ 1 และเรียกผู้เสียหายที่ 3 ว่า โจทก์ร่วมที่ 2

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 มาตรา 7 (2), 11 วรรคหนึ่ง, 48 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 17 วรรคหนึ่ง, 24 วรรคหนึ่ง, 48, 50 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 108, 110 (1) ระวังโทษตาม มาตรา 108 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 เรียกกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 โดยไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มประกอบกิจการโรงงาน ปรับ 10,000 บาท ฐาน

ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบโดยไม่ได้รับอนุญาต ปรับ 10,000 บาท ฐานมีไว้เพื่อขาย
ซึ่งยาเส้นและยาสูบที่มีได้ปิดแสมป์ยาสูบ ปรับ 95,746,875 บาท ฐานปลอม
เครื่องหมายการค้าและมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเป็น
กรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทแต่ละบทโทษเท่ากัน ให้ลงโทษฐานปลอม
เครื่องหมายการค้า ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 1 ปี รวมจำคุก 1
ปี และปรับ 95,766,875 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 29, 30 หากต้องกักขังแทนค่าปรับให้กักขังเป็นระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งปีแต่
ไม่เกินสองปีได้ ริมของกลางให้เป็นของกรมสรรพสามิต ยกเว้นรถยนต์กระบะ
หมายเลขทะเบียน 9 ห - 9125 กรุงเทพมหานคร ให้คืนแก่เจ้าของข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า
"คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกับพวก ร่วมกันกระทำความผิดหลายข้อหา การที่ศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางอนุญาตให้โจทก์ร่วมทั้งสองเข้า
ร่วมเป็นโจทก์โดยไม่ระบุว่าอนุญาตในข้อหาใด ซึ่งหมายความว่าอนุญาตให้เข้าร่วม
เป็นโจทก์ในทุกข้อหาตามฟ้อง ย่อมไม่ถูกต้อง เพราะโจทก์ร่วมทั้งสองซึ่งอ้างว่าเป็น
เจ้าของเครื่องหมายการค้าตามฟ้องเป็นผู้เสียหายได้เฉพาะในข้อหาทำปลอม
เครื่องหมายการค้าและมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีตราเครื่องหมายการค้าปลอม
เท่านั้น ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใด
อุทธรณ์ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศก็มีอำนาจ
ยกขึ้นวินิจฉัยและพิพากษาให้ถูกต้องได้ สำหรับการกระทำความผิดตามฟ้องซึ่งศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า จำเลยมีความผิด
และลงโทษรวม 4 กระทง คือ ร่วมกันประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 โดยไม่แจ้ง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน ร่วมกันประกอบอุตสาหกรรมยาสูบโดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพสามิต ร่วมกันมีयाสาบชนิดบุหรืชิกาแรตและยาเส้นปรูงที่มิได้ปิดแสตมป์ยาสาบไว้เพือขาย และร่วมกันทำปลอมเครื่องหมายการค้าและมีไว้เพือจำหน่ายสินค้าที่มีตราเครื่องหมายการค้าปลอมอันเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทและแต่ละบทระวางโทษเท่ากัน ให้ลงโทษฐานทำปลอมเครื่องหมายการค้า ส่วนข้อหาอื่นให้ยกนั้น จำเลยอุทธรณ์แต่ฝ่ายเดียว ความผิดข้อหาอื่นตามฟ้องโจทก์ไม่อุทธรณ์จึงเป็นอันยุติไปตามคำพิพากษาศาลทรรพ์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

...พิเคราะห์แล้ว โจทก์มีนายวินัยเป็นพยานเบิกความว่า เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2544 จำเลยขอเช่าโรงรถที่บ้านนายวินัยเพือเก็บเครื่องจักรผลิตพลาสติก แต่นายวินัยปฏิเสธเพราะไม่รู้จักกันมาก่อน ต่อมาปลายเดือนสิงหาคม 2544 จำเลยให้นายบุญเลิศซึ่งเป็นญาติห่างๆ ของนายวินัยพาไปติดต่อขอเช่าอีก นายวินัยจึงตกลงให้เช่า หลังจากนั้นจำเลยนำเครื่องจักรผลิตบุหรืชิกาแรตของกลาง จำนวน 2 เครื่องไปติดตั้งและนำชาวจีนหญิงและชายหลายคนไปขอพักอาศัยชั่วคราวด้วยโดยบอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวซึ่งมีอาชีพเป็นวิศวกร วันที่ 2 พฤศจิกายน 2544 ก็เริ่มเดินเครื่องจักรโดยใช้กระแสไฟฟ้าที่จำเลยต่อไปจากโรงงานของจำเลยซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่และเดินเครื่องจักรเรื่อยมาจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2544 ที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตเข้าตรวจค้นจับกุม และนายวินัยได้เบิกความตอบคำถามค้านว่า เมื่อทราบว่จำเลยใช้โรงรถที่เช่าเป็นที่ผลิตบุหรืชิการแรต นายวินัยบอกให้จำเลยขนย้ายเครื่องจักรกับบุหรืออกไปภายใน 15 วัน เนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายซึ่งก็สอดคล้องกับคำให้การชั้นสอบสวนของนายวินัยตามบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา กับโจทก์มีนายอาทิตย์เบิกความเป็นพยานประกอบบันทึกคำให้การของพยานได้ความสอดคล้องกับคำเบิกความของนายชูชัย และนายสมาน เจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้ร่วมตรวจค้นจับกุมว่า ในชั้นจับกุม นายวินัยให้การว่า จำเลยเป็นผู้ติดตั้งเครื่องจักรสำหรับผลิตบุหรืเถื่อน โดยบอกว่าขอเช่าบ้านนายวินัยทำโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก เห็นว่า นายวินัยไม่ได้

เป็นจำเลยในคดีนี้ ข้อเท็จจริงที่ได้ความจากคำเบิกความและคำให้การของนายวินัยดังกล่าวจึงมิใช่เป็นการขัดทอดจำเลยในคดีเดียวกัน ทั้งนายวินัยให้การและเบิกความเป็นอย่างเดียวกันมาโดยตลอดว่า จำเลยเป็นผู้นำเครื่องจักรผลิตบุหรี่ยี่ห้อเรตไปติดตั้งและผลิตบุหรี่ยี่ห้อเรตของกลาง และไม่มีข้อสงสัยว่า นายวินัยจะปรักปรำจำเลย โดยเฉพาะจำเลยเองก็เบิกความตอบคำถามค้านรับว่า นายวินัยเป็นคนซื้อและไม่มีพิษมีภัยต่อใคร คำให้การและคำเบิกความของนายวินัยดังกล่าว แม้เป็นคำขัดทอดก็เป็นพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักในการรับฟังเพื่อประกอบข้อเท็จจริงที่ฟังได้ยุติดังกล่าวข้างต้นและพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ได้ ที่อุทธรณ์จำเลยอ้างว่า นายวินัยให้การขัดทอดถึงจำเลย เนื่องจากนายวินัยกับจำเลยมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน จากกรณีที่นายวินัยเป็นนายหน้าแนะนำนายบุญเลิศให้เป็นผู้รับเหมาร้างโรงงานให้จำเลย และนายบุญเลิศเบิกเงินล่วงหน้าแล้วแต่ทิ้งงานไป เมื่อจำเลยทวงเงินคืนจากนายวินัยและนายบุญเลิศก็ทะเลาะกันถึงขั้นรุนแรงนั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ได้ความจากคำเบิกความของจำเลยว่า จำเลยรู้จักกับนายวินัยครั้งแรก เมื่อจำเลยไปดูการถมที่ดินเพื่อสร้างโรงงานและพบนายวินัยกับภริยากำลังทำสวนอยู่บริเวณหลังที่ดินที่ถมนั้น เมื่อทราบว่าจำเลยซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติก นายวินัยเสนอขายที่ดินของตนแก่จำเลยด้วย แต่จำเลยปฏิเสธ นายวินัยจึงแนะนำให้จำเลยว่าจ้างนายบุญเลิศซึ่งจำเลยทราบภายหลังว่าเป็นญาตินายวินัย สร้างโรงงานให้ โดยรับรองว่านายบุญเลิศเป็นช่างฝีมือดีและจะช่วยดูแลให้ หากเกิดความเสียหาย นายวินัยจะรับผิดชอบเอง เห็นว่า ข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงให้เห็นได้อย่างมากที่สุดเพียงว่า เมื่อทราบว่าจำเลยกำลังถมที่ดินเพื่อสร้างโรงงานนายวินัยต้องการช่วยเหลือให้นายบุญเลิศซึ่งเป็นญาติกันได้รับการว่าจ้างจากจำเลยให้สร้างโรงงานนั้นเท่านั้น ส่วนจำเลยย่อมทราบดีว่าคำรับรองของนายวินัยดังกล่าวเป็นเพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความเหมาะสมของนายบุญเลิศที่จะรับสร้างโรงงานซึ่งจำเลยก็เบิกความเองว่าตกลงค่าจ้างกันถึง 2,700,000 บาท ได้ แต่ในกรณีที่หากเกิดความเสีย

หายขึ้นจากการกระทำของนายบุญเลิศ จำเลยไม่มีข้ออ้างใด ๆ ตามกฎหมายที่จะ
บังคับให้นายวินัยร่วมรับผิดชอบหรือรับผิดชอบนายบุญเลิศได้ โดยเฉพาะอุทธรณ์จำเลย
ที่อ้างว่า เมื่อประมาณกลางเดือนตุลาคม 2544 จำเลยทวงเงินที่นายบุญเลิศเบิกล่วงหน้า
คืนจากนายวินัยและนายบุญเลิศ มีการทะเลาะกันถึงขั้นรุนแรงนั้น กลับได้รับความ
จากคำเบิกความของจำเลยว่า จำเลยเองเป็นฝ่ายโกรธมากถึงกับฉีกสัญญาว่าจ้าง
ก่อสร้างโรงงานทิ้งและขู่ว่าจะฟ้องทั้งนายวินัยและนายบุญเลิศ แล้วจำเลยกลับไปพา
ลูกน้องมาอีก 4 ถึง 5 คน บอกให้นายวินัยรับผิดชอบ เมื่อนายวินัยปฏิเสธโดยบอก
ให้ไปคุยกับนายบุญเลิศเอง จำเลยก็ขู่ว่าจะดำเนินคดีอาญาข้อหาฉ้อโกงด้วย ซึ่งแสดง
ว่าจำเลยแต่ฝ่ายเดียวมีความโกรธเคืองถึงขนาดพาพวกอีกหลายคนกลับไปข่มขู่นาย
วินัย และแม้จะฟังได้ตามที่จำเลยเบิกความว่า นายวินัยทำให้จำเลยฟ้อง ก็ถือได้ว่า
เป็นเพียงการตอบโต้ต่อการข่มขู่ของจำเลยเท่านั้น ไม่น่าเชื่อว่านายวินัยจะมีความ
โกรธเคืองและอาฆาตแค้นรุนแรงถึงขนาดที่จะต้องปรักปรำจำเลยให้ต้องรับโทษใน
คดีนี้ ดังจะเห็นได้จากคำเบิกความของจำเลยและเอกสารประกอบแผ่นซีดีหมายเลข 26
ที่จำเลยถอดความส่งตามคำสั่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง ซึ่งได้ความว่าก่อนวันเริ่มสืบพยานจำเลยในวันที่ 1 พฤษภาคม 2546 ที่จำเลย
อ้างตนเองเข้าเบิกความเป็นพยานปากแรกจำเลยไปหานายวินัยที่บ้าน 2 ครั้ง ครั้ง
แรก เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 อ้างว่าไปกับทนายความเพื่อส่งหมายเรียกให้แก่
นายทั้งคู่อัยจำเลยที่ 2 ในคดีที่นายวินัยเป็นจำเลยที่ 1 และครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2546 อ้างว่าไปกับทนายความและเจ้าพนักงานตำรวจอีกคนหนึ่งเพื่อพูดคุย
เกี่ยวกับเรื่องการเบิกเงินของนายบุญเลิศและการใช้กระแสไฟฟ้าจากโรงงานจำเลย
โดยเจ้าพนักงานตำรวจผู้นั้นได้แอบบันทึกเหตุการณ์ปรากฏตามแผ่นซีดีหมายเลข 26
ไว้ด้วย อันแสดงให้เห็นว่า นายวินัยมิได้มีการโกรธเคืองจำเลยแม้แต่น้อยจึงให้การ
ต้อนรับและพูดคุยด้วยอย่างปกติโดยมิได้เฉลียวใจว่าจะมีการลักลอบบันทึก
เหตุการณ์ครั้งที่สองไว้ สำหรับแผ่นซีดีหมายเลข 26 ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ

การคำระหว่างประเทศกลางไม่รับฟังเป็นพยานหลักฐาน และอุทธรณ์จำเลยโต้แย้งว่า จำเลยมีสิทธิอันชอบธรรมในการค้นหาความจริงและพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจำเลย ทั้งโจทก์และโจทก์ร่วมก็ไม่ได้คัดค้านว่าภาพและเสียงที่บันทึกในแผ่นซีดีดีหมาย ล.26 ไม่ใช่ภาพและเสียงของนายวินัยกับภริยานายวินัย จึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้นั้น เห็นว่า พฤติการณ์ในการบันทึกเหตุการณ์ลงในแผ่นซีดีดีหมาย ล.26 ดังกล่าวข้างต้นที่ว่าเป็นการลักลอบกระทำก่อนวันที่จำเลยอ้างตนเองเข้าเบิกความเป็นพยานเพียง 1 วัน ประกอบกับการที่จำเลยเบิกความตอบคำถามค้านว่า ปัจจุบันจำเลยไม่ได้โกรธเคืองกับนายวินัยแล้ว เพราะต้องการจะได้ข้อมูลตามที่ปรากฏในแผ่นซีดีดีหมาย ล.26 และตอบคำถามถึงว่าเหตุที่ทำดีกับนายวินัยเนื่องจากจำเลยฉีกเอกสารหลักฐานที่ว่าจ้างนายบุญเลิศก่อสร้างโรงงานทิ้งไปแล้ว จึงพยายามหาหลักฐานใหม่ เป็นข้อเท็จจริงที่ชี้ชัดว่าแผ่นซีดีดีหมาย ล.26 เป็นพยานหลักฐานที่จำเลยทำขึ้นใหม่ด้วยการทำเป็นดีกับนายวินัย แล้วลักลอบบันทึกเหตุการณ์นั้นไว้ ถือได้ว่าเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการหลอกลวงและด้วยวิธีการที่มีชอบ ต้องห้ามมิให้อ้างเป็นพยานหลักฐานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 26 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางไม่รับฟังแผ่นซีดีดีหมาย ล.26 เป็นพยานหลักฐาน จึงชอบแล้วและที่อุทธรณ์จำเลยโต้แย้งการใช้ดุลพินิจซึ่งน้ำหนักพยานหลักฐานของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางโดยอ้างว่า ในคดีที่นายวินัยเป็นจำเลย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าคำเบิกความของนายวินัยไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานโจทก์และลงโทษนายวินัยแต่ในคดีนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกลับรับฟังคำเบิกความของนายวินัยในเรื่องเดียวกัน และข้อเท็จจริงเดียวกันเพื่อลงโทษจำเลยนั้นเห็นว่าคดีที่นายวินัยถูกฟ้องเป็นจำเลยมีปัญหา

ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางต้องพิจารณาและวินิจฉัยว่านายวินัยกับจำเลยอื่นอีก 10 คน ร่วมกันกระทำความผิดหรือไม่ ซึ่งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางใช้ดุลพินิจซึ่งน้ำหนักพยานหลักฐานแล้วเห็นว่า คำเบิกความของนายวินัยที่ว่าจำเลยเป็นผู้เช่าบ้านที่เกิดเหตุเป็นที่ตั้งของโรงงานและนายวินัยไม่ได้ร่วมกระทำความผิดด้วย ไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ที่พิสูจน์ความผิดของนายวินัยได้ ส่วนเรื่องที่ว่าจำเลยร่วมกระทำความผิดด้วยหรือไม่นั้น ไม่เป็นปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในคดีที่นายวินัยถูกฟ้องเป็นจำเลย ฉะนั้น การที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางรับฟังคำเบิกความของนายวินัยในคดีนี้ เป็นพยานหลักฐานโจทก์อย่างหนึ่งที่พิสูจน์ความผิดของจำเลย และเมื่อใช้ดุลพินิจซึ่งน้ำหนักคำเบิกความของนายวินัยดังกล่าวประกอบกับพยานหลักฐานอื่นของโจทก์แล้วเชื่อว่าจำเลยร่วมกระทำความผิดจึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ขัดแย้งกับการใช้ดุลพินิจในคดีที่นายวินัยถูกฟ้องเป็นจำเลยแต่อย่างใด เพราะเป็นการวินิจฉัยคนละปัญหากันส่วนข้ออ้างในอุทธรณ์จำเลยประการอื่นเกี่ยวกับน้ำหนักความน่าเชื่อถือของคำเบิกความของนายวินัยนั้น ล้วนแต่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยไม่เป็นสาระแก่คดี จึงไม่วินิจฉัยให้ อุทธรณ์จำเลยประการแรกนี้ฟังไม่ขึ้น

สำหรับสายไฟฟ้าที่มีการโยงจากที่ดินที่จำเลยกำลังสร้างโรงงาน นำกระแสไฟฟ้าที่จำเลยเป็นผู้ขอใช้ในระบบ 3 เฟส 4 สาย 380 โวลต์ ขนาดหม้อแปลง 250 KVA ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมไปใช้ในการประกอบกิจการโรงงานที่เกิดเหตุตามที่ฟังได้ยุติดังกล่าวข้างต้นนั้น นอกจากอุทธรณ์จำเลยจะรับว่า จำเลยรู้เห็นยินยอมด้วยกับการที่นายวินัยดำเนินการโยงสายไฟฟ้าดังกล่าวแล้ว อุทธรณ์จำเลยที่ว่า จำเลยไม่ทราบเลยว่านายวินัยจะใช้กระแสไฟฟ้าของจำเลยในการกระทำความผิดคดีนี้ก็ไม่สมเหตุสมผลและมีข้อพิรุธหลายประการ กล่าวคือ ข้ออ้างที่ว่าจำเลยอนุญาตให้นายวินัยดำเนินการได้เพราะนายวินัยรับรองว่าจะออกค่าไฟฟ้าเองมีจำเลยเพียงปากเดียวเบิกความกล่าวอ้างลอยๆ และใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่จำเลย

อ้างส่งเพื่อเป็นพยานหลักฐานสนับสนุนว่า นายวินัยออกค่าไฟฟ้าเองนั้นนอกจากเป็นใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2545 ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2544 ที่เหตุคดีนี้เกิดขึ้นแล้ว จำเลยยังเบิกความตอบคำถามค้านรับว่าไม่ทราบว่าใครเป็นผู้จ่ายเงินตามใบเสร็จรับเงินดังกล่าว ข้ออ้างที่ว่าเหตุที่จำเลยมีเรื่องโกรธเคืองกับนายวินัยเมื่อประมาณกลางเดือนตุลาคม 2544 ดังกล่าวข้างต้นแล้ว แต่จำเลยยังคงให้นายวินัยใช้กระแสไฟฟ้าต่อไปเพราะนายวินัยขอร้อง ก็ไม่สมเหตุสมผลกับการที่จำเลยโกรธนายวินัยมากถึงกับมีการขู่ว่าจะดำเนินคดีแก่นายวินัยทั้งทางแพ่งและทางอาญา ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นข้อพิรุธที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยมีส่วนได้เสียกับนายวินัยเป็นพิเศษในการที่นายวินัยใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อทำความผิดคดีนี้ จำเลยจึงยังคงให้นายวินัยใช้กระแสไฟฟ้าต่อไป ส่วนข้ออ้างที่ว่าหากจำเลยมีส่วนร่วมกระทำผิดจริงแล้วการโยงสายไฟฟ้าจากที่ดินที่จำเลยกำลังสร้างโรงงานไปยังบ้านนายวินัยซึ่งเป็นที่เกิดเหตุ คงต้องโยงแบบลับๆ เพื่อปกปิดมิให้บุคคลอื่นพบเห็นได้ง่าย ไม่ใช่เป็นการโยงพาดกับเสาไม้ด้านบนโดยเปิดเผย เป็นการโยงในลักษณะชั่วคราวซึ่งสามารถตรวจสอบและสามารถมองเห็นได้โดยง่าย ทั้งจำเลยไม่น่าจะเปิดเผยชื่อในการขอใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ก็ไม่สมเหตุสมผลเช่นกัน เพราะได้ความจากคำเบิกความตอบคำถามค้านของนายภาณุ พยานโจทก์ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน ซึ่งตรวจสอบการใช้กระแสไฟฟ้าของโรงงานที่เกิดเหตุว่า ในขณะที่เกิดเหตุคดีนี้ บริเวณโรงงานที่เกิดเหตุอยู่ในซอยลึกเข้าไปเป็นถนนลูกรังและก่อสร้างเป็นโรงงานรายแรกในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งจำเลยเป็นผู้ขอใช้ไฟฟ้าแรงสูงเป็นรายแรก เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงมิได้เข้าไปตรวจสอบโดยละเอียด ทำให้ไม่พบว่าการโยงสายไฟฟ้าจากที่ดินที่จำเลยกำลังสร้างโรงงานไปยังโรงงานที่เกิดเหตุ ซึ่งจำเลยก็น่าจะรู้ข้อเท็จจริงนี้ดีจึงรู้เห็นยินยอมให้มีการโยงสายไฟฟ้าในลักษณะที่ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายนอกจากนี้เมื่อ

นายภานุเบิกความยืนยันด้วยว่า การโยงสายไฟฟ้านำกระแสไฟฟ้าจากโรงงานของจำเลยซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขออนุญาตใช้กระแสไฟฟ้าไปใช้ในที่หนึ่งคือโรงงานที่เกิดเหตุเป็นการขัดต่อระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำเลยก็ได้ถามค้านหรือนำสืบให้เห็นว่าจำเลยไม่ทราบว่าการที่อนุญาตให้นายวินัยโยงสายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ทั้งการที่จำเลยขอใช้ไฟฟ้านั้น จำเลยต้องยื่นคำขอตามแบบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดพร้อมกับหลักฐานคือบัตรประจำตัวประชาชน ดังนั้นหากจำเลยไม่เปิดเผยชื่อและมีหลักฐานดังกล่าวยืนยัน จำเลยก็ไม่อาจขอให้กระแสไฟฟ้าได้ อุทธรณ์จำเลยที่ว่าจำเลยไม่ทราบเลยว่า นายวินัยจะใช้กระแสไฟฟ้าของจำเลยในการกระทำความผิดคดีนี้จึงฟังไม่ขึ้น ส่วนข้ออ้างที่ว่านอกจากโรงงานที่เกิดเหตุแล้ว ยังมีโรงงานอื่นอีก 2 โรงงาน ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับที่ดินที่จำเลยสร้างโรงงานขออนุญาตโยงสายไฟฟ้านำกระแสไฟฟ้าใช้เช่นกันนั้น เมื่ออุทธรณ์จำเลยเองรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุคดีนี้แล้ว และเป็นการติดต่อขออนุญาตจากภริยาจำเลย เพราะขณะนั้นจำเลยกำลังถูกคุมขังอยู่ในคดีนี้ จึงเป็นเรื่องที่ไม่เป็นสาระแก่คดีและไม่วินิจฉัยให้ และที่อุทธรณ์จำเลยอ้างว่า หลังจากมีการตรวจค้นและจับกุมในที่เกิดเหตุแล้ว จำเลยไม่ได้หลบหนี แต่คงทำธุรกิจการค้าอยู่ที่โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกของจำเลยตลอดมาโดยไม่ทราบว่าถูกออกหมายจับนั้น นอกจากจะได้ความจากคำเบิกความของนายชัชชัย ผู้ใหญ่บ้านท้องที่ที่เกิดเหตุซึ่งเป็นพยานโจทก์ว่า หลังจากมีการจับกุมผู้กระทำความผิดที่โรงงานที่เกิดเหตุเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2544 การสร้างโรงงานของจำเลยก็หยุดไปเช่นกันแล้ว จำเลยก็เบิกความตอบคำถามค้านเจือสมว่า นายบุญเลิศหยุดการก่อสร้างโรงงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2544 และสภาพที่ดินและโรงงานตามภาพถ่ายที่จำเลยอ้างส่งยังแสดงให้เห็นด้วยว่าจนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2546 ที่มีการระบุไว้ในภาพถ่ายนั้นเองว่าเป็นวันที่ถ่ายภาพดังกล่าว จำเลยได้ทิ้งร้างทั้งที่ดินและโรงงานที่สร้างไปได้เพียงเล็กน้อยตลอดมาคำเบิกความของจำเลยที่อ้างว่านับตั้งแต่นายวินัยกับพวกถูกจับกุม จำเลยยังคงประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์พลาสติกจำหน่ายตามปกติโดยอ้างส่งใบรับคำสั่งซื้อสินค้าและใบส่งของ
สนับสนุนนั้น เป็นการเบิกความที่กล่าวอ้างลอยๆ และเอกสารดังกล่าว ก็เป็นเอกสาร
ที่จำเลยทำขึ้นเอง ไม่มีลูกค้าผู้สั่งซื้อและรับสินค้ารับรองความถูกต้องทั้งเป็นเพียง
สำเนาภาพถ่าย จึงไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถืออุทธรณ์จำเลยที่อ้างว่าปัจจุบันจำเลยได้ก่อสร้าง
โรงงานให้แล้วเสร็จเพื่อให้ธุรกิจของจำเลยได้ขยายตลาดการขายผลิตภัณฑ์พลาสติก
มากยิ่งขึ้นโดยอ้างภาพถ่ายทำอุทธรณ์สนับสนุนนั้น เมื่อพิจารณาภาพถ่ายดังกล่าว
แล้วกลับเห็นได้ว่ายังเหลืองานที่ต้องสร้างต่ออีกมากจึงจะแล้วเสร็จแต่ที่สำคัญก็คือ
เป็นการกล่าวอ้างที่ขัดแย้งกับคำเบิกความของจำเลยเองที่อ้างว่าการที่จำเลยถูก
จับกุมและคุมขังในคดีนี้ ทำให้ธุรกิจจำเลยประสบภาวะการณ์ขาดทุนต้องเลิกกิจการ
ผลิตจานชามและแก้วพลาสติกและภริยาจำเลยต้องจดทะเบียนตั้งบริษัทขึ้นใหม่เพื่อ
ดำเนินธุรกิจอย่างอื่นซึ่งปรากฏตามหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าหน้ากากโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบตเตอรี่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซองโทรศัพท์เคลื่อนที่และหูฟัง เห็นว่า คำเบิกความของจำเลยที่
เจือสมพยานหลักฐานโจทก์และความไม่สมเหตุสมผลของข้ออ้างในอุทธรณ์จำเลยดัง
กล่าวข้างต้นประกอบคำเบิกความของจำเลยที่อ้างว่าการที่โรงงานยังสร้างไม่เสร็จ
ทำให้จำเลยต้องไปเช่าที่ดินผู้อื่นในท้องที่อื่นสร้างโรงงานผลิตสินค้าไปก่อน ล้วนแต่
เป็นข้อพิรุธที่แสดงให้เห็นว่า จำเลยร่วมกระทำความผิดด้วย จึงหลบหนีโดยทิ้งร้าง
ที่ดินและโรงงานที่เพิ่งสร้างไปได้เพียงเล็กน้อย และหันไปเช่าที่ดินในท้องที่อื่นเพื่อ
สร้างโรงงานอย่างเดียวกันแทน อันทำให้จำเลยต้องยอมใช้เงินลงทุนเพิ่มขึ้นอีกเป็น
จำนวนมาก ทั้งคำเบิกความของจำเลยที่อ้างว่า ขณะที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 28
มิถุนายน 2545 จำเลยกำลังจะเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อติดต่อ
ธุรกิจเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ก็ไม่น่าเชื่อเพราะขัดกับคำเบิกความของจำเลยเอง
ดังกล่าวข้างต้นที่อ้างว่าธุรกิจดังกล่าว ภริยาจำเลยเป็นผู้ดำเนินการหลังจากที่จำเลย
ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2545 อุทธรณ์จำเลยที่ว่าจำเลยไม่ได้หลบหนีฟังไม่

ขึ้นเช่นกัน ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามที่โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบ ซึ่งเมื่อพิจารณา ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ฟังได้ยุติดังกล่าวข้างต้นแล้ว เชื่อได้ว่าจำเลยกระทำความ ผิดฐานร่วมกันประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 โดยไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทราบก่อนร่วมกันประกอบอุตสาหกรรมยาสูบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม สรรพสามิตร่วมกันมียาสูบชนิดบุหรี่ยี่ห้อเรตและยาเส้นปรุงที่มีได้ปิดแสตมป์ยาสูบไว้ เพื่อขายและร่วมกันมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีตราเครื่องหมายการค้าปลอม ดังที่ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัย อุทธรณ์จำเลยใน ส่วนนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า อนุญาตให้โจทก์ร่วมทั้งสองเป็นโจทก์ร่วมได้แต่เฉพาะใน ข้อหาทำปลอมเครื่องหมายการค้าและมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีตรา เครื่องหมายการค้าปลอมกับให้ยกฟ้องในข้อหาทำปลอมเครื่องหมายการค้า โดยให้ ลงโทษจำเลยฐานมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม จำคุก 1 ปี และเมื่อรวมกับความผิดฐานอื่นแล้ว รวมจำคุก 1 ปี ปรับ 95,766,875 บาท นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศกลาง

(กนก อินทร์ทรัพย์-สุวัฒน์ วรรณะหทัย-พิชิต คำแฝง)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

ในเรื่องของการแอบบันทึกเสียงเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีนั้นศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ว่ารับฟังได้ไม่ขัดประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1123/2509) โดยในคดีนั้นผู้ที่แอบบันทึกเสียงคือโจทก์ร่วม แต่ในคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ การแอบบันทึกเหตุการณ์ (บันทึกทั้งภาพและเสียง) เกิดขึ้นจากฝ่ายของจำเลย ซึ่งกระทำโดยเจ้าพนักงานตำรวจ เพื่อเป็นหลักฐานในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจำเลย แต่ศาลฎีกาก็ไม่รับฟังโดยให้เหตุผลว่าขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 ตามกฎหมายเยอรมัน ความเห็นฝ่ายข้างมากเห็นว่าพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หากกระทำโดยเอกชนแล้วไม่ต้องห้ามรับฟังเพราะหลักในเรื่องการไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบนั้นใช้เฉพาะกับกรณีที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเจ้าพนักงานของรัฐเท่านั้น ดังนั้น แม้จะได้หลักฐานมาเพราะไปลักมาหรือโดยการหลอกลวง ซึ่งเป็นการขัดต่อหลักในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน 136a ตามความเห็นฝ่ายข้างมากแล้ว พยานหลักฐานดังกล่าวก็รับฟังได้ ข้อยกเว้นของหลักการดังกล่าวข้างต้น มีสองกรณีคือ กล่าวคือ กรณีแรกเป็นกรณีที่การได้มาซึ่งพยานหลักฐานโดยเอกชนนั้นเป็นการขัดต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์เช่นการทรมาน เป็นต้น กรณีที่สองจะเป็นกรณีที่การได้มาซึ่งพยานหลักฐานโดยเอกชนเป็นการละเมิดต่อสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวด้วยการแอบบันทึกเสียง (Vgl. Joecks, Studienkommentar StPO, 2.Auflage 2008, บทนำ, หัวข้อ 221) ในกรณีที่สองศาลฎีกาเยอรมันตัดสินไว้ในคดี BGHSt 14, 358 (Vgl. Roxin, Strafverfahrensrecht, 25.Auflage 1998, บทที่ 24, หัวข้อ 48) คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ คงไม่อาจกล่าวได้ว่าการแอบบันทึกเหตุการณ์ทั้งภาพและเสียงนั้นเกิดขึ้นจากเจ้าพนักงานของรัฐตามหลักในเรื่องการห้ามรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบที่จะมีผลทำให้พยานหลักฐานดังกล่าว

คือแผ่นซีดีดีหมาย ล.26 ต้องห้ามมิให้รับฟังเพราะมิใช่เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำเพื่อที่จะเอาตัวจำเลยมาลงโทษ หากแต่เป็นกรณีกลับกัน กล่าวคือพยานหลักฐานดังกล่าวคือแผ่นซีดีดีหมาย ล.26 ถูกทำขึ้นเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ ความบริสุทธิ์ของจำเลย แผ่นซีดีดีหมาย ล.26 จึงเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจาก การกระทำของเอกชน (คือจากฝ่ายจำเลย) ซึ่งโดยหลักแล้วสามารถรับฟังเป็นพยาน หลักฐานได้ แต่เนื่องจากการแอบบันทึกเหตุการณ์ทั้งภาพและเสียงนั้นเป็นการ ละเมิดต่อสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวอันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 35 (พ.ศ.2550) แผ่นซีดีดีหมาย ล.26 จึงต้องห้ามมิให้รับฟัง อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกาในคดี นี้ให้เหตุผลในการไม่รับฟังแผ่นซีดีดีหมาย ล.26 ว่าเป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 226 ซึ่งก็เท่ากับว่าศาลฎีกานำหลักในประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 ไปใช้กับกรณีของการกระทำของเอกชนด้วย ผู้ เขียนหมายเหตุเห็นว่า หลักในเรื่องการไม่รับฟังพยานหลักฐานตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226 ต้องเป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากการกระทำ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ใช่จากการกระทำของเอกชน เหตุผลในข้อนี้จะเห็นชัดถ้าเรา พิจารณาความเห็นของนักกฎหมายอเมริกันในเรื่องพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ ที่ศาลอเมริกันปฏิเสธไม่ยอมรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวเพื่อที่จะได้เป็นการยับยั้ง การกระทำที่มิชอบของเจ้าพนักงานของรัฐ นักกฎหมายเยอรมันที่เห็นไปในทำนอง เดียวกันกับนักกฎหมายอเมริกันเห็นจะมีเพียงศาสตราจารย์ Volk ที่มองว่าหลักในเรื่อง การไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบนั้นมีผลในทางป้องกันทั่วไปด้วย (Generalpraeventiv) กล่าวคือ จะทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่กระทำการใดๆ ที่จะไร้ ประโยชน์เนื่องจากผลของการกระทำดังกล่าวไม่สามารถรับฟังได้ (Vgl.Volk, Grundkurs StPO, 6.Auflage 2008, บทที่ 28, หัวข้อ 7) สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์ หมายเหตุ ข้อเท็จจริงตามฎีกานี้น่าจะเป็นเรื่องการแสวงหาหรือการได้มาซึ่งพยาน หลักฐานที่ไม่ชอบ ซึ่งตามบทบัญญัติของ ป.วิ.อ. เดิมมีแต่มาตรา 226 ที่กำหนดไม่

ให้รับฟังพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยมิชอบ และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2547 ได้เพิ่มบทตัดพยานหลักฐานเกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่งพยานหลักฐานในชั้นจับกุมตามมาตรา 84 วรรคท้าย และในชั้นสอบสวนตามมาตรา 134/4 วรรคท้าย โดยบัญญัติให้เจ้าพนักงานปฏิบัติให้ถูกต้องตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ กล่าวคือในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนหากเจ้าพนักงานไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามวิธีการที่กำหนดไว้ในชั้นจับกุมหรือชั้นสอบสวนก็ย่อมส่งผลให้พยานหลักฐานที่ได้มานั้นต้องห้ามมิให้รับฟังทันทีโดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบต่อไปว่า พยานหลักฐานนั้นเกิดขึ้นโดยไม่ชอบตามมาตรา 226 หรือไม่ เช่น ในชั้นจับกุมหากเจ้าพนักงานผู้จับกุมไปสอบถามคำให้การและผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ คำให้การรับสารภาพนั้นก็มิอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ (ถึงแม้ว่าผู้ต้องหาสมัครใจรับสารภาพโดยดีก็ตาม) ต่อมาเมื่อปี 2551 ได้มี พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.อ. (ฉบับที่ 28)ฯ เพิ่มมาตรา 226/1 เพื่อให้ครอบคลุมถึงพยานหลักฐานที่ได้มาเนื่องจากการกระทำที่มิชอบทุกประเภท ดังนั้น มาตรา 226/1 จึงเป็นการสร้างความชัดเจนในเรื่องผลของบทตัดพยานหลักฐานระหว่างพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยมิชอบซึ่งเป็นบทตัดพยานหลักฐานเด็ดขาดตามมาตรา 226 กับพยานหลักฐานที่ได้มาเนื่องจากการกระทำโดยมิชอบซึ่งเป็นบทตัดพยานหลักฐานที่มีข้อยกเว้นตามมาตรา 226/1 คำพิพากษาศาลฎีกาเก่าๆ ที่เหมารวมระหว่างพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นโดยมิชอบจึงเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาเนื่องจากการกระทำโดยมิชอบว่าต้องห้ามตามมาตรา 226 จึงไม่น่าจะใช้เป็นบรรทัดฐานได้ต่อไป และต้องนำข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป มาวิเคราะห์ว่า เป็นกรณีตามมาตรา 226 หรือมาตรา 226/1 การพิจารณาคำพิพากษาศาลฎีกาเก่าๆ บางเรื่องที่วินิจฉัยตามมาตรา 226 หากเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหลังจากมาตรา 226/1 มีผลใช้บังคับแล้ว และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องประกอบตามมาตรา 226/1 ก็ต้องถือว่าเป็นบทตัดพยานหลักฐานตามมาตรา 226/1 ดังเช่น การทำธงคำตอบของข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) พ.ศ.2552 ที่มีการนำข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5294/2549 มาออกข้อสอบซึ่งตาม

คำพิพากษาศาลฎีกานั้นวินิจฉัยว่า เป็นกรณีของมาตรา 226 แต่ตรงคำตอบปรับแก้เป็น
มาตรา 226/1 จึงเป็นไปตามที่ผู้หมายเหตุวิเคราะห์ไว้ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาล
ฎีกานี้ก็เช่นกันน่าจะต้องปรับเข้ากับ มาตรา 226/1 ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พรเพชร
วิชิตชลชัย